

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2273/2548

นางสาวภัทรานุช ชัยอุดม  
เทศบาลนครนนทบุรี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 264  
ป.วิ.พ. มาตรา 226

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นคำสั่งก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี แม้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 264 ก็เป็นคำสั่งในขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองอาคารเลขที่ 73/69/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่ 13071 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของนายกำพล วัชรุกิจจา จำเลยที่ 3 มีหนังสือแจ้งคำสั่งรื้อถอนตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้โจทก์รื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างพร้อมทั้ง

กระถางต้นไม้ที่กีดขวางและปิดกั้นทางเข้า - ออกทั้งหมด และให้ทำทางให้อยู่ในสภาพเดิม ต่อมาโจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จำเลยที่ 4 ถึง 12 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ และจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของจำเลยที่ 3 ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ถึงที่ 12 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กล่าวคือ โจทก์มีอำนาจโดยชอบที่จะทำการก่อสร้างในที่ดินที่โจทก์ครอบครอง หากจะออกคำสั่งบังคับโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำเลยที่ 3 ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 เสียก่อน จะบังคับโจทก์ตามมาตรา 42 เสียทีเดียวหาได้ไม่ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 ถึงที่ 12 ดังกล่าวเสีย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า ปี 2533 นายกัมพล ใช้กิจจา กับพวกเคยร่วมกันก่อสร้างดัดแปลงและก่อสร้างปิดกั้นกีดขวางทางเข้าออกบริเวณที่พิพาทเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปและที่อาศัยและครอบครองอาคารตึกแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีกัน ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้นายกัมพล ใช้กิจจา กับพวกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปิดกั้นกีดขวางทางเข้า - ออก และทำทางให้อยู่ในสภาพเดิม และได้ทำการบังคับคดีแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 918/2535 ต่อมาโจทก์ได้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารพิพาทปิดกั้นกีดขวางทางเข้า - ออกบริเวณที่ได้มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างกีดขวางบริเวณที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวไปแล้วขึ้นมาอีกโดยไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ และเพราะขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และนอกจากบริเวณพิพาทจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณพิพาท ซึ่งเป็นทางภาระจำยอมที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานหลายปีแล้ว บริเวณ

ดังกล่าวย่อมถือเป็นที่สาธารณะตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 กรณีจึงไม่สามารถที่จะมีคำสั่งให้โจทก์ทำการ ดัดแปลงหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องว่า คำนิยามความหมายคำว่า ที่สาธารณะ หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 6, 26, 28, 29 และ มาตรา 48 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำนิยามความหมายของคำว่า ที่ สาธารณะ หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทาง สัญจรได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องของโจทก์ ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ให้ยก คำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น ต้น คำสั่งศาลชั้น คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของโจทก์ ที่ขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นคำสั่งก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสิน คดี แม้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มาตรา 264 ก็เป็นคำสั่งในขั้นตอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล  
ยุติธรรมต้องถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นใน  
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 การที่ศาล  
อุทธรณ์ภาค 1 รับวินิจฉัยจึงไม่ถูกต้อง และการที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์จึงไม่  
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
ภาค 1 และยกฎีกาของโจทก์

(สดศรี สัตยธรรม-วิชัย วิวิตเสวี-นันท์ชัย เพียรสนอง)

แหล่งที่มา                      สำนักวิชาการ

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

| ต้น | หมายเหตุ |
|-----|----------|
|-----|----------|